

1500956-07.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... de já estar preso em flagrante por tráfico, ele confessou que estava praticando o tráfico então já deu voz de prisão a ele, mesmo assim solicitou permissão e ele autorizou. A vistoria no imóvel foi acompanhado por ele próprio, porém, antes disso deixou-o na viatura, ele entregou o controle do portão, ingressando primeiramente para constatar se havia mais alguém na residência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500956-07.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500956-07.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID ISRAEL BISPO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra DAVID ISRAEL BISPO, qualificado à fl. 04, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 13h45min, na Rodovia Júlio Budisk, n.º 1, Conjunto Habitacional Ana Jacinta, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o denunciado transportava e trazia consigo droga, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido de 4,47g (quatro gramas e quarenta e sete centigramas - lacre nº 0035541). Consta dos inclusos autos, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo supracitadas, na Rua Onitro Campos de Amaral, nº 145, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o denunciado tinha em depósito droga, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 06 (seis) porções de cocaína, com peso líquido de

3,52g (três gramas e cinquenta e dois centigramas - lacre nº 0035541), tudo conforme boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, fotografias de fls. 22/25, laudo de constatação de fls. 39/41 e exame químico-toxicológico definitivo às fls. 104/106. Segundo se apurou, o denunciado DAVID ISRAEL BISPO adquiriu as porções de cocaína acima mencionadas de terceira pessoa até o momento não identificada e passou a transportar 02 (duas) porções na motocicleta Honda CG 160, Titan, placa EBE-0H50, azul, ano 2018/2019, de Presidente Prudente/SP, bem como manteve em depósito em sua casa 06 (seis) porções da mesma substância, com vistas a comercializá-las ilicitamente. Na data dos fatos, em patrulhamento de rotina, os policiais militares avistaram a motocicleta supracitada e um veículo modelo Hb20 estacionados próximos e, quando os seus respectivos condutores notaram a viatura, o motorista do Hb20 evadiu-se, enquanto o condutor da motocicleta, depois identificado como sendo o denunciado DAVID, tentou nela subir para sair do local, mas foi abordado pelos agentes públicos antes de empreender fuga. Em revista pessoal, foram localizados 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido de 4,47g, na posse do imputado, além de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro, sem comprovação de origem lícita, em seu short, próximo ao cóccix, armazenados em uma carteira plástica. O denunciado estava em vias de alienar o entorpecente ao motorista do veículo Hb20 quando sucedeu a abordagem policial. Ante a suspeita de que mantinha mais entorpecente em sua moradia, os policiais se deslocaram até o local, onde apreenderam com a anuência do denunciado mais 06 (seis) papelotes de cocaína, com peso líquido de 3,52g, além de R\$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, sem prova de procedência lícita. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, somada à quantidade e a natureza altamente nociva da substância entorpecente apreendida, adquirida de pessoa até o momento não identificada, já embaladas para a venda, afigura-se quadro seguro a apontar que a droga apreendida seria destinada ao comércio espúrio de substâncias entorpecentes.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 155/163), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 167/169), o despacho de fls. 170/174, de 10 de dezembro de 2021, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 230/236), pediu a total procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Por sua vez, a ilustre Dr^a. Defensora (fls. 238/243), requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28, da Lei nº 11343/06, pois o réu alega em Juízo ser usuário de drogas. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, que seja aplicada a pena no mínimo legal, em regime semiaberto, devendo ser reconhecida a confissão espontânea do réu.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11; pelas fotografias de fls. 22/25; pelo laudo de constatação preliminar de fls. 39/41; pelo laudo químico toxicológico de fls. 104/106, atestando - Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0035541) Descrição: 2 (dois) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo "zip") encerrando porção de material sólido particulado branco. Massa Bruta e/ou Quantidade: 10,59 grama(s) - dez gramas e cinquenta e nove centigramas. Massa Líquida: 4,47 grama(s) - quatro gramas e

quarenta e sete centigramas. Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0035542) Descrição: 6 (seis) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo "zip") encerrando porção de material sólido particulado branco. Massa Bruta e/ou Quantidade: 10,42 grama(s) - dez gramas e quarenta e dois centigramas. Massa Líquida: 3,52 grama(s) - três gramas e cinquenta e dois centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, o PM Rejunior Guimarães da Silva, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento pelo Jardim Santa Fé pela Rodovia Julio Budisck, sob o viaduto do Ana Jacinta, visualizou dois veículos, um HB20 prata e uma moto CG azul, e o único indivíduo da moto se aproximando do veículo HB20 quando ele notou a aproximação da viatura e empreendeu fuga. Optaram por acompanhar a motocicleta que estava mais fácil, e o abordaram e em revista pessoal foram localizadas em suas vestes, duas porções de cocaína, uma carteira plástica continha RR\$ 210,00 em notas diversas, uma CNH, e indagado sobre o entorpecentes, o acusado disse que iria vender aquela droga para o indivíduo do HB20 pela quantia de R\$ 100,00 cada papelote, haviam dois, e indagado se na residência havia mais drogas, ele disse que em cima da geladeira havia mais seis papelotes pesando 25 gramas de cocaína comprada pelo valor de R\$ 1.000,00, e que faria com essa quantidade, R\$ 2.500,00 de lucro. Diante dos fatos deslocaram-se até a residência de Davi onde encontraram em cima da geladeira, os seis papelotes de cocaína, no seu quarto em uma carteira mais R\$ 800,00 em espécie, acionado o canil para localização de armas e drogas, porém, nada mais de ilícito foi localizado. Davi também informou que já foi preso duas vezes por tráfico de cocaína, conduzido ao distrito. Na casa não tinha mais ninguém, a esposa trabalhava e as filhas não estavam. Sobre o dinheiro que estava na casa tinha nas coisas de sua esposa, mas a carteira onde foi encontrado dinheiro era dele. Estavam em quatro ou cinco na abordagem. Nenhum conseguiu anotar a placa do veículo, pois trata-se de uma baixadinha e optou por abordar o motociclista para não perder nenhum nem outro. Não pediu apoio porque queria constatar primeiro alguma situação de crime, evitando um risco desnecessário a outras equipes. Afirma que ele autorizou o ingresso em sua residência, pois além de já estar preso em flagrante por tráfico, ele confessou que estava praticando o tráfico então já deu voz de prisão a ele, mesmo assim solicitou permissão e ele autorizou. A vistoria no imóvel foi acompanhado por ele próprio, porém, antes disso deixou-o na viatura, ele entregou o controle do portão, ingressando primeiramente para constatar se havia mais alguém na residência para segurança da equipe e dele próprio, e como não havia mais ninguém, foi retirado da viatura e nos acompanhou durante as buscas. Não foi possível visualizar nenhuma característica do veículo ou de qualquer ocupante do HB20.

O PM Gabriel Fernando Diomázio Figueira, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento próximo ao bairro Santa Fé, pela rodovia Julio Budisck, no viaduto que leva ao bairro Ana Jacinta, quando avistamos um veículo prata e uma motocicleta, e o motociclista dirigia-se rumo ao veículo e notando a aproximação da viatura, retornou para a moto e o veículo arrancou do local, sendo abordado o motociclista e com ele foi encontrado dois papelotes de cocaína na linha da cintura. Questionado a respeito, ele disse que venderia as duas porções para o ocupante do veículo por R\$ 200,00 e que pesava cada uma 1,5 gramas. Questionados se havia mais drogas, disse que em cima da geladeira havia mais seis porções de cocaína e que saiu da prisão recentemente. Deslocaram-se até a residência dele, onde acompanhado e autorizado por ele, ingressamos na residência e no local informado foi encontrado mais 6 porções de cocaína, e em seu quarto encontramos a quantia de R\$ 800,00, e acionado o canil, nada mais foi encontrado, ratificando a voz de prisão. Afirma que a equipe era formada por quatro policiais, e estavam neste dia. Afirma que era um veículo prata, aparentando ser um HB20. Não fizeram pedido de apoio a outras equipes, porque optamos por abordar o motociclista, e nesse momento desembarcou da viatura como comandante de equipe e o quarto homem, não ficou ninguém no rádio. Não comunicaram outra equipe acerca daquele veículo.

Afirma que autorizou a entrada na casa do David, por ele mesmo que acompanhou as buscas, afirma que primeiramente adentraram na casa para saber se havia mais alguém, e como não tinha mais ninguém, retornamos e ele nos acompanhou nas buscas, além disso, a casa é inteira monitorada por câmeras, tanto fora como dentro da casa e ele acompanhou toda a vistoria.

A testemunha Neutina Maria Cardoso Lima, declarou que é vizinha da mãe de David e o conhece desde o ano de 1995. Sob o crivo do contraditório declarou que não assistiu e nem presenciou a abordagem da Polícia na casa de David, pois é vizinha da casa da mãe dele. Conhece o David desde criança, sempre foi menino trabalhador, e ultimamente sabe que ele saiu da cadeia e que ele trabalhava com sua esposa na confecção de canecas. Conhece bem a mãe dele.

A testemunha Ana Claudia de Lima, disse que conhece o réu há um bom tempo, trabalha com a esposa do acusado, pois faz faxina durante a semana, e ajuda na confecção de copos. Sob o crivo do contraditório declarou que não assistiu e nem presenciou a prisão do réu, não viu a vistoria na casa dele. Sabe que David é honesto, trabalhador, e viu que quando chegava ele saía ou já tinha saído para trabalhar. Sabe que ele é usuário de drogas, porque a esposa tinha lhe contado, um dia ela desabafou que estava atrás de uma clínica para interna-lo. afirma que fazia "bicos" na casa do réu e não percebia movimento de pessoas estranhos no local, e sobre a dependência química dele, disse que ela vai a igreja e pediu ajuda para o pastor ajuda-la a interna-lo.

O réu David Israel Bispo, em seu interrogatório declarou que já foi preso e cumpriu pena de prisão por uso de drogas. Quanto aos fatos disse que por volta das 9:30 ou 10 horas saiu para comprar cocaína, quando no Brasil Novo pegou seis papelotes e como ele não tinha mais a quantidade que eu queria, quando foi preso e pego com dois pinos, sendo abordado e encontrado com ele esses dois pinos e disse que tinha na minha casa e eles encontraram o que tinha comprado pela manhã. Afirma que a droga era para seu próprio uso. Disse que conversou com um rapaz do carro prata que lhe vendeu os dois papelotes de cocaína que faltava, e o encontro foi próximo ao Leite Lider na ponte, e isso ocorreu na parte da manhã, saiu para trabalhar e foi comprar. Na tabacaria comprou R\$ 1.000,00 de drogas, mas como ele não tinha a quantidade que queria, combinou de pegar o resto na parte da tarde, quando foi buscar. Disse que quanto a ter autorizado a entrada dos policiais em sua residência, ficou o tempo todo dentro da viatura, mas não os autorizou a entrarem em sua residência e não acompanhou quando eles encontraram a droga. Afirma que sua esposa pediu para o pastor da igreja que frequenta para interna-lo numa clínica. Não sabe se surgiu vaga ou não, pois foi preso. Afirma que estava ajudando a esposa e fazendo "bico" de pedreiro e pintura. Disse que sua profissão é motorista, já teve comercio, uma conveniência.

A negativa do réu David não pode ser acolhida, em primeiro, porque desmentida, tanto pela versão apresentada na fase inquisitiva, quando narrou, de forma muito objetiva, algumas peculiaridades que não foram confirmadas em Juízo, tais como, que o amigo que estava no veículo estava esperando para ir para uma chácara, quando avistou a viatura, ligou o carro e "saiu fora". Estava com os dois papelotes que usariam na chácara. O amigo do HB20 "não deu para conhecer". Ele veio para mostrar como chegar na chácara, questionado se não usaria com "o amigo", respondeu "o outro rapaz estava na chácara". Faz bico como servente e pintura, mas sua profissão é motorista de circular. Já trabalhou na PrudenExpress, TCP, Vitapeli. Afirma que já foi preso por tráfico por duas vezes. Questionado sobre o teste para renovar CNH profissional, disse ter renovado há pouco tempo, mas começou a usar a droga a menos tempo ainda: "agora esses dias". Na residência mora com a esposa e as duas filhas. Dada a palavra ao advogado, perguntou sobre o dinheiro, ao que disse o interrogando que parte do dinheiro é da esposa, que trabalha na gráfica Impress. Ela recebe por débito conta, mas também faz serviço em casa, por fora, de copos, máscaras, a mesma coisa que faz na gráfica.

Também é artificiosa a narrativa de não ter autorizado a entrada dos policiais em sua residência, ficou o tempo todo dentro da viatura, mas não os autorizou a entrarem em sua residência e não acompanhou quando eles encontraram a droga, entretanto, ao que se observa na mídia anexada em alegações finais pelo Ministério

Público, não se vê qualquer atividade de buscas domiciliar sem a presença do réu, pelo contrário, ele foi conduzido até dentro de sua residência e no momento em que encontraram as drogas, indicadas pelo próprio réu, se fazia presente. Quando mostra os policiais sozinhos dentro da residência, é corriqueira tal abordagem, a fim de verificarem se há algum perigo dentro da residência, já que estão ingressando em local desconhecido, devendo ter bastante cautela, até mesmo para proteção do acusado.

Também é desmentida pelas palavras dos policiais, que informaram ter visto o réu parado com a motocicleta e indo em direção a um veículo de cor prata, talvez um HB20, mas quando percebeu a aproximação da viatura, voltou correndo para a moto na tentativa de fugir do local, sendo abordado e com ele foi encontrado em sua cintura dois papелotes de cocaína.

Por fim, a palavra dos policiais serve para sustentar a demonstração dos fatos e a condenação do réu.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

“PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))”.

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que “como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” - “Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))”

Observe-se que o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas

circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que "em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário" (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que "pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis" (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278). Observa-se que a palavra do réu não merece qualquer credibilidade, já que cheia de falsidade e inverdades, pois, no momento que foi preso, os policiais disseram que quando ele percebeu a presença da viatura da Polícia Militar, voltou correndo para sua moto, dessa forma, ninguém que iria comprar drogas, e foi de alguma forma impedido, impossibilitado ou interceptado durante o trajeto, consegue concretizar a negociação, então, com ele é encontrado as drogas que ele próprio disse que foi buscar, não convence.

Também é de se causar estranheza quando disse conhecer as pessoas do carro que iam para uma chácara, igualmente difícil de crer nessa versão, porque estariam parados num lugar ermo, para irem a outro lugar, no caso uma chácara, e lá iriam usar a droga com outra pessoa que, supostamente, já estaria lá. Ora, então qual o sentido de pegar as drogas com os indivíduos do carro, se todos iam para o mesmo local e lá usariam as drogas, não faz nenhum sentido, mesmo porque todos tentaram fugir do local. Outra situação divergente e que causa estranheza, é quem vive somente de serviços de bico de pedreiro e de pintor, tem um patrimônio que o réu demonstra possuir, justamente pelas câmeras de sua residência, demonstrando que há certo luxo, com várias câmeras instaladas em volta da casa e dentro dela, e em plena segunda-feira, dia que foi preso, iria usar drogas numa chácara, não condiz e nem chega perto do estilo de vida de pessoas que trabalham nesse ramo, pelo contrário, aparenta viver muito bem, com patrimônio vultoso, sem compromisso com trabalho, difícil para quem acabou de sair da prisão, e que lá esteve por duas vezes, anteriormente.

Com efeito, a quantidade de droga apreendida e pertencente ao réu (8 porções de cocaína pesando 8,0 gramas), bem como numerário (R\$ 800,00), além das circunstâncias que se desenvolveram os fatos e o firme relato das testemunhas Policiais Militares, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Ademais, o desencontro das versões apresentadas pelo réu, que acabam se confundindo entre eles, justamente porque não encontram justificativas para a droga, o dinheiro, encontradas no imóvel usado para esconder drogas, portanto, sua versão é fantasiosa e desconexa com o conjunto probatório coligido aos autos.

Também não prospera a alegação de que a droga era para consumo próprio, pois, os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, pela, ocorrência dos fatos como informado através da Polícia Militar; não só da droga mas também do dinheiro, decorrente da venda do entorpecente, num total de R\$ 1050,00 (mil e cinquenta reais), sendo R\$ 250,00 apreendida com David e R\$ 800,00 em sua residência, o que por si só, não denotam o crime de tráfico, mas aliada as demais circunstâncias, demonstram à sociedade a atividade espúria desenvolvida pela acusado.

Outrossim, a droga apreendida, conforme se vê nas fotografias de fls. 22/25, corroborado com os depoimentos dos policiais, era suficiente para demonstração da traficância, e além do mais, o réu nada trouxe aos autos que pudesse comprovar a origem lícita do numerário apreendido em sua posse, o que faz crer que era fruto da traficância de drogas por ele exercida.

Por outro lado, desnecessário a apreensão de apetrechos para a configuração do crime.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero

ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

No mais, o acusado foi surpreendido pelos policiais no exato momento da prática delitiva, o que constitui, desta forma, a evidência do fato punível, a certeza visual do crime.

Portanto, o estado de flagrância é prova que milita em desfavor do réu.

Neste prisma, colaciono julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: "Nunca, é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5a ed., 11/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente.

Nesse sentido:

"PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento: - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente." (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)" (TJSP Apelação nº 01112349.3/7-0000-000. Rel. Eugênio Augusto Clementi Júnior, j. em 05.12.2007).

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa do réu e nem o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a condição de traficante, sua nítida intenção é na tentativa de confundir o espírito do julgador e com isso, furtar-se a um provável édito condenatório.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal. Importante ressaltar, inclusive, que tanto transportava e trazia consigo como tinha em depósito, escondido em sua residência, demonstram a principal destinação das drogas.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal nº 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal nº 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal nº 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado. E o que se infere dos autos, é justamente como ocorria no

momento que a polícia encontrou o réu em atitude suspeita.

Nesse sentido: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745); "Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Por fim, fica devidamente evidenciado que o réu, a fim de evitar transitar com grande quantidade de droga, guardava na residência, de onde retirava parte para a venda a terceiro, inclusive, fazia as entregas com seu veículo, enquanto a maior parte ficava escondida na residência.

Diante de tudo que foi azealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas, sendo certo que o traficante, muitas vezes, também é usuário de droga, sem perder a qualidade primária, procedendo a ação penal como pedido na denúncia.

Neste sentido:

"Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Quantidade de droga e a forma de acondicionamento demonstram a traficância. Impossibilidade de desclassificação para o uso. Depoimentos de policiais, contra os quais nada de concreto se alegou. Condenação bem proferida. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (Ap. Criminal nº 990.10.183740-4 - Registro - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator Desembargador Francisco Bruno).

A propósito:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

"Tóxico Tráfico Desclassificação - Inadmissibilidade - Ausência de prova de que a droga apreendida destinava-se ao uso exclusivo do réu - Ônus da prova a cargo da defesa - Condenação mantida para o crime de tráfico que restou indubitavelmente comprovado nos autos." (Apelação Criminal n.º 270.095-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 24.06.99 - V.U.).

Destarte, as provas produzidas permitem a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de trazer consigo, transportar e ter em depósito droga e, com isto, auferir lucro fácil, não podendo ser acatadas as teses da Defesa de insuficiência probatória, negativa de autoria e desclassificatória para o artigo 28, da Lei em comento.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Por tudo isto é que procede a ação penal e, de rigor a sua condenação.

Passo a dosagem da pena.

Verifica-se que consta em sua folha de antecedentes criminais e certidão de distribuição de processos de fls. 42/45, que já foi condenado recentemente por crime de tráfico de drogas, e demonstram que, pouco tempo após cumprir a pena, veio a ser novamente processado por idêntico crime, demonstrando que seu comportamento não é merecedor de quaisquer benefícios, agravando sua situação, pois faz do crime de tráfico de drogas o seu meio de subsistência, e para agravar a pena base em razão dos maus antecedentes indico o processo (Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0023900-07.2012.8.26.0482 (0023900-07.2012.8.26.0482) 09/01/2013 Sentença Condenatória (Art. 33 "caput" § 4º do(a) SISNAD; Reclusão: um ano e oito meses; Regime: Fechado; Multa de 166 dias.

Valor da multa R\$ 3.441,73) 21/01/2013 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 04/02/2013 Recurso Interposto (Recebo o recurso do réu. Tipo de Recurso: Apelação Criminal: 13/06/2013 Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação (Art. 33 "caput" § 4º do(a) SISNAD) 10/07/2013 Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação).

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que lhes são desfavoráveis, todavia o processo servirá para anotação da sua reincidência, fixo a pena base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pagar a multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante genérica da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, referente a condenação definitiva nos autos do Processo (fls. 43/44 - Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara das Execuções Criminais. Execução da Pena: 0009773-64.2018.8.26.0996 (0000422-79.2017.8.26.0583). Data: 31/05/2021. Autor: Justiça Pública. 16/07/2018 Sentença Condenatória (Art. 33 "caput" c/c Art. 29 "caput" ambos do(a) SISNAD; Reclusão: cinco anos e dez meses; Regime: Fechado; Multa de 583 dias. Valor da multa R\$ 18.209,03;) 16/07/2018 Publicação da Sentença 23/07/2018 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 03/08/2018 Término da Prisão 03/08/2018 Transferência do Preso (Tipo de prisão: Sentença Condenatória; Local de prisão: São José do Rio Preto - CPP "Dr. Javert de Andrade") 13/08/2018 Recurso Interposto 25/06/2019 Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação (Art. 33 "caput" c/c Art. 29 "caput" ambos do(a) SISNAD; Reclusão: cinco anos e dez meses; Regime: Fechado; Multa de 583 dias. Valor da multa R\$ 18.209,03; Situação: Reincidente doloso;) 19/07/2019 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação), de modo que aumento em 1/6 (um sexto) a pena base aplicada. Ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que a torna definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a pagar a multa de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Não faz o réu jus a redução da pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão ter respondido e condenado definitivamente em dois processos por tráfico de drogas, entretanto, reconhecendo-se os maus antecedentes e a reincidência específica, pois já condenado definitivamente por crime de tráfico, e de acordo com o artigo 44, da Lei nº 11.343/06 impede o benefício ao réu.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.464/06, o que não fere qualquer princípio constitucional, uma vez que está em conformidade com o disposto no art. 5.º, incs. XXXIX, XLVI e XLIII, da Constituição Federal.

Ademais, é incompatível outro regime, pois se trata de crime equiparado a hediondo, portanto, de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade, inclusive, por ser possuidor de maus antecedentes e já ter sido condenado por crime de tráfico de drogas anteriormente, único compatível com sua condição.

Inviável qualquer substituição diante do montante da pena, pelos mesmos motivos acima expostos.

Incabível o "sursis", por não preencher os requisitos do artigo 77, inc. II, do Código Penal e por ser incompatível com o regime semiaberto previsto na Lei 8072/90.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu DAVID ISRAEL BISPO, RG: 40116120, CPF: 310.349.488-22, nascido em 27/01/1982, natural de Rancharia - SP, filho de JOSEFINA GERMANO BISPO, a cumprir a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar a multa de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Ainda sobrevivem os motivos da decretação da prisão preventiva dos réus nestes autos e por terem eles respondido todo o processo preso, agora imponho-lhe a obrigação de recolher-se à prisão para poder apelar desta sentença.

Vale ressaltar que, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a manutenção da prisão preventiva no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, "não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, §1.º, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma" (RHC 47.674/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 22/08/2014).

INCONTINENTE, comunique-se a sentença no presídio que ele se encontrar.

INCONTINENTE, comunique-se esta sentença para instruir os autos do Habeas Corpus nº 2269984-24.2021.8.26.0000, onde figura como paciente, David Israel Bispo, em trâmite na 5ª Câmara de Direito Criminal, tendo como Relator, Desembargador Geraldo Wohlers.

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Decreto a perda em favor da UNIÃO de todo o numerário e do veículo apreendido nos autos, posto que oriundo do tráfico de drogas.

Determino a imediata destruição dos aparelhos celulares apreendidos nos autos, que segundo a perícia foram utilizados para a prática do tráfico de drogas.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA